

1502050-65.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502050-65.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502050-65.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2288220/2020 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 14762662 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 4088/20/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE RODRIGUES PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

HENRIQUE RODRIGUES PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 22h25min, na Avenida Fênix, altura do nº 1410, bairro Alves Dias, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo, para fins de comercialização, drogas consistentes em 15,09g de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 07 invólucros plásticos; 8,51g de

cocaína, divididos em 19 invólucros plásticos; e 1,53g de cocaína na forma de crack, fracionados em 12 invólucros plásticos, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 12/13, laudo de constatação provisório de 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 79/81.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Fênix, bairro Alves Dias, onde há conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, quando visualizaram o acusado parado embaixo de uma árvore.

Ao notar a aproximação da viatura, o acusado se afastou do local, o que motivou a abordagem policial.

Em sua posse, no bolso da calça, foram encontradas 19 porções de cocaína, 7 porções de maconha e 12 porções de crack, além da quantia de R\$ 16,00, em notas trocadas. Indagado informalmente, o acusado admitiu que estava traficando. Diante disso, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Considerando a significativa quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento – em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros – a apreensão de valores em dinheiro, produto da mercancia ilegal, assim como as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, que se deu em local conhecido como ponto de venda de drogas, não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a págs. 04/63. Notificado por edital (págs.120/121), o réu ofertou defesa preliminar (pág.140) Recebida a denúncia a (págs. 142/143), o réu foi citado por edital (pág. 152).

O réu não compareceu espontaneamente e não constituiu defensor nos autos, aplicando-se o artigo 366 do Código de Processo Penal.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado por descumprimento das medidas cautelares (págs. 156/158). O mandado de prisão foi cumprido em 11 de outubro de 2022 (págs. 186/187). O réu foi citado pessoalmente (pág. 219). A defesa arrolou as mesmas testemunhas qualificadas na denúncia (pág.222).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, a acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito vem demonstrada no auto de exibição e apreensão de págs. 12/13 (dinheiro e droga), nos laudos de constatação às págs.15/17 e químico-toxicológico às págs.79/81 e no comprovante de depósito de pág. 72.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág. 07), em Juízo o acusado confessou a prática do delito nos termos da denúncia. Para justificar a conduta, declarou que passava por dificuldade financeira.

O acusado confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido: “Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-

la.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Jeferson de Jesus Fabri e Henrique Morillas de Souza, em relato coeso e harmônico com o anterior, relataram os passos da diligência que realizaram na data dos fatos e espanearam qualquer dúvida quanto à autoria:

Realizavam patrulhamento pelo local do fato, uma praça onde há conhecido ponto de venda de droga, quando visualizaram o acusado – parado e sozinho - debaixo de uma árvore. Era por volta de 22h25min.

Ao notar a presença policial, o acusado passou a caminhar, buscando afastar-se do local. Olhava todo o tempo para a viatura, Diante da suspeita conduta, realizaram a abordagem.

Efetuada revista pessoal, na pochete que o réu trazia na cintura foram localizadas porções individuais de cocaína em pó, crack e maconha, além de quantia em dinheiro trocado.

Inquirido, o réu admitiu a mercancia ilícita. Disse que tinha sido expulso de casa e precisava de dinheiro.

Não conheciam o acusado antes da abordagem acima relatada.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos.(...)E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015).

A ausência de qualificação de civis como testemunhas, por si só, não leva à absolvição da agente, diante da conhecida dificuldade de tal diligência em crimes da natureza do ora tratado (geografia do local, 'lei do silêncio', dentre outros fatores).

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade e a espécie da substância entorpecente apreendida (19 invólucros plásticos de cocaína, 07 invólucros plásticos de maconha e 12 invólucros plásticos contendo crack), a forma como acondicionada (individualmente), o local da prisão (conhecido ponto da mercancia ilícita), a apreensão de dinheiro trocado e as circunstâncias da prisão tornam evidente que a droga destinava-se ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ponto, cumpre anotar, outrossim, que a circunstância do réu não ter sido preso no momento em que efetuava a venda da droga a usuário, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consoma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Para justificar a conduta criminosa, o acusado declarou que passava por dificuldade financeira, pois tinha sido expulso de casa.

Tal fato, por si só, não configura o estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não autoriza a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida.

Cabia ao acusado demonstrar situação de extrema necessidade e que agira visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa (CPP, art.156). De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Não há prova de que o acusado não teria condições de encontrar forma lícita para a obtenção de sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Portanto, o acusado realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Não há agravantes a considerar. Embora presente a menoridade relativa e a confissão espontânea (CP, art.65, I e III, "d"), deixo de reduzir a reprimenda porque as

atenuantes não permitem a fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Não há causas de aumento de pena.

Incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº11.343/06. O réu preenche todos os predicados legalmente previstos. É primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova de que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa.

Não há óbice à aplicação do índice redutor máximo, considerando-se a quantidade de droga apreendida em poder do réu.

Assim, pelas razões alhures, reduzo a pena em 2/3, o que perfaz 01anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. O índice é proporcional à conduta perpetrada pelo acusado.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o aberto. Não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena não altera a tipificação contida no caput do referido preceito legal (ou seja, em que pese a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, a prática do "tráfico privilegiado" continua a ser considerada tráfico de drogas, ainda hediondo).

Esse entendimento chegou a ser reforçado pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas." (Súmula 512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).

Ocorre que, no julgamento do HC nº 118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Para o Supremo Tribunal Federal, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência.

Essa decisão foi acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.

Ainda assim, tais decisões encontravam-se desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam adstritos ao entendimento ali professado.

Ante a inexistência de resolução do Senado acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram seu posicionamento de que o "tráfico privilegiado" era equiparado a crimes de natureza hedionda.

Esse foi no entendimento perfilhado por este Juízo por anos, mantendo-se a natureza de crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ocorre que a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime") trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado":

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução histórica, que

aos poucos se fortificou no sentido de considerar o “tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.

Adotar uma premissa válida para a Lei de Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas medidas”.

A persecução penal, fundamentalmente, está separada em três fases bem distintas, a saber: A investigação, o processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo, dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés, continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de conhecimento. O direito é único.

No entanto, o direito, como ciência que é, está sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação social, possibilitando, sempre, sua interpretação e modificação de entendimento, no todo, ou em parte.

Por tais razões, este Juízo alterou, nessa parte, posicionamento anterior, depois de muita reflexão e ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente, quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao regime inicial para expiação da pena corporal.

Diante das alterações legislativas recentes, deve ser realizada interpretação sistemática, passando-se a adotar o tráfico privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto.

Fundamenta-se o regime na exegese do artigo 59, caput, e seu inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pena base foi fixada no mínimo legal. O réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedica à atividades criminosas. Confessou a prática do crime. Sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Cumpra-se, outrossim, a recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP.

De outra parte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do “sursis”, não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A concessão de tais benesses descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Na espécie, o réu portava quantidade razoável de droga. Embora seja possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito não constitui medida recomendável pois não teria o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do inculpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína. O crime é de perigo abstrato.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado HENRIQUE RODRIGUES PINTO, qualificado nos autos às págs.25/28, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro

detalhado.

O réu respondeu ao processo preso, decretada sua prisão preventiva às págs.186/187. Diante da pena e regime aplicados, o réu poderá recorrer em liberdade, não mais presentes os requisitos da prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Decreto o perdimento do dinheiro, oriundo do tráfico de droga.

De imediato, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição da substância entorpecente apreendida nos autos.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e tornem os autos conclusos para designação de audiência admonitória;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

d) Providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD, informando sobre a decretação do perdimento da quantia apreendida e o local do depósito.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA